

1520555-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520555-27.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520555-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232277/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19858981 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2992/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2232277 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO GOMES ROSA DE MACEDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

GUSTAVO GOMES ROSA DE MACEDO, qualificado nos autos, está sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 15h20min, na Rua Helvetia, altura do nº 100, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comércio, um tijolo de maconha, com peso líquido total de 444,6g e 62 papérolas da mesma droga, somando 31,6g, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva após decisão proferida pelo Juízo de plantão (fls.88/89).

Notificado (fls.99), o réu apresentou defesa preliminar em fls. 105/110. A denúncia foi recebida aos 06 de outubro de 2021, em fls.116/117, sendo concedido o benefício da liberdade provisória ao acusado. O laudo de exame químico toxicológico foi juntado em fls. 142/144 dos autos. O réu foi citado em audiência, durante a qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, com interrogatório ao final. Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova e entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos da denúncia, afastando-se o redutor em razão da quantidade de entorpecentes e da prisão por processo posterior. A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de uso, a aplicação da pena no mínimo legal, o cômputo da causa especial de redução da pena, a fixação de regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda e a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, a despeito do esforço argumentativo da Defesa. A materialidade do crime restou evidenciada pelo auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 29/32, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 142/144, prova técnica que atestou serem maconha e cocaína as substâncias encontrada em poder do acusado. A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo. A testemunha Elienai Fonseca da Silva, guarda municipal, disse que estava na rua Helvétia para acompanhar a subida do "fluxo" na Cracolândia, como faziam diariamente. Visualizaram o rapaz caminhando com um volume embaixo do braço. que esboçou uma reação estranha, o que ensejou a abordagem. Feita a revista, viram que ele carregava um tijolo de maconha, embaixo do braço, e envelopes de cocaína, nos bolsos da jaqueta que ele vestia. Salvo engano eram 60 envelopes de cocaína, além de R\$ 200,00 em dinheiro. O réu disse que não sabia o que eram os envelopes ou o tijolo, que achou na confusão do fluxo. Não conhecia o réu anteriormente. O réu nada disse sobre ser usuário, e tampouco demonstrava estar sob efeito de drogas. A testemunha Jean Tchaly Guimarães Ferreira Pereira corroborou o relato da testemunha Elienai, mas disse que o réu empreendeu fuga no momento da tentativa de abordagem. O réu informou que havia encontrado as drogas no meio do "fluxo", nada tendo dito sobre a finalidade da obtenção das drogas. Conhecia o réu apenas de vista, da própria região. Ele estava subindo a rua no meio dos demais adictos. As porções de cocaína estavam dentro de um saco plástico, do tipo sacola de mercado, enrolados. Não chegou a ver o réu anteriormente usando drogas ou vendendo drogas, mas apenas transitando pela região. Ao ser interrogado em Juízo, o réu disse que é dependente químico há muitos anos, e frequenta o "fluxo". Naquele dia, quando se realizaria a limpeza do local, encontrou algumas porções de drogas onde ficam as barracas dos traficantes, dentro de um caixote. É costume dos usuários procurar drogas nesses locais, as quais sempre caem, então decidiu pegar para seu uso próprio. Vivia na rua há um ano e pouco., está preso por tráfico de drogas, ainda não foi proferida sentença. Já foi condenado por uso de entorpecentes. Estudou até o primeiro colegial, trabalhava vendendo balas. Acabou de fazer 20 anos. Como visto, a negativa do réu restou completamente isolada no contexto probatório, não sendo amparada por qualquer elemento fático. Com efeito, esclareceram os guardas civis que estavam em patrulhamento de rotina, quando viram o réu com um volume embaixo do braço, em local apontado como ponto de tráfico de drogas. O acusado, ao perceber a aproximação dos guardas, esboçou nervosismo. Durante a abordagem, ao submetê-lo à busca pessoal, localizaram o tijolo de maconha e as porções de cocaína, estas embaladas em forma própria para venda.

Note-se que, no caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos guardas civis, sendo cioso notar ter restado incontroverso que não existiam anteriormente animosidades entre os guardas e o réu, pelo que suas declarações merecem credibilidade.

Assim, a prova produzida pela acusação autoriza a condenação do acusado pelo crime de tráfico, na medida em que absolutamente firmes os depoimentos das testemunhas no sentido de que foi encontrada a droga na posse do denunciado, parte já devidamente embalada para venda, conforme se verifica da fotografia acostada em fls. 32.

Saliente-se, ainda, que diante das condições em que encontradas as drogas, especialmente da quantidade e notadamente da forma como acondicionadas, vale dizer, em porções individuais, certo é que serviriam à entrega e ao consumo de terceiros. Evidente, portanto, o descabimento da pretensão da defesa quanto à desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06, não merecendo acolhida a fantasiosa versão do acusado de que teria localizado razoável quantidade de entorpecentes "esquecida" nas barracas usadas pelos traficantes de drogas.

Nesta medida, ainda que o acusado não tenha sido flagrado durante a efetiva entrega de entorpecentes a terceiros, na tradição, deve ser condenado nos termos da imputação inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

É o que basta à condenação pelo crime de tráfico de entorpecente, dada a robustez, coerência e firmeza da prova amealhada aos autos.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário, não podendo a condenação por fato posterior de fls. 141 ser utilizada em seu desfavor, assim como o feito ainda em andamento (fls. 140). De outro lado, a quantidade de entorpecentes com ele encontrada não é exacerbada, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, verifico que a menoridade relativa do réu não tem o condão de ensejar a fixação da pena abaixo do mínimo legal, remanescendo a pena inalterada. Na terceira fase, a despeito da discordância ministerial, reputo viável a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque o processo criminal ainda em trâmite contra o réu não pode ser considerado em seu prejuízo, sob pena de lesão ao princípio da presunção de inocência. Ademais, a condenação do réu como usuário de entorpecentes, transitada em julgado, não enseja a conclusão do envolvimento do réu em atividades criminosas, até porque referente a fato posterior ao delito em tela, de modo a afastar a incidência do redutor legal. De igual modo, a quantidade de entorpecentes apreendida nos autos é insuficiente para configurar, por si só, a habitualidade criminosa impeditiva da benesse legal. Acrescente-se, mais uma vez, que o réu é tecnicamente primário, tudo a possibilitar a diminuição da reprimenda em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar à míngua de quaisquer outras circunstâncias a serem consideradas.

Como assentado pelo Tribunal Pleno do Colendo STF, "... o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa ..." (STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016).

Desse modo, reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada,

cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como por uma pena de multa, calculada no mínimo legal. Aplica-se, aqui, mais uma vez, o raciocínio de que as condenações posteriores e processos em andamento não podem ser considerados em desfavor do réu.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GUSTAVO GOMES ROSA DE MACEDO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pena de multa, na forma anteriormente determinada, sendo ainda calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixados pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não existir razões informadas nos autos para sua exacerbação.

O réu é primário e poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a pena fixada e o regime de seu cumprimento.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena fixada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA